I INTRODUÇÃO

O vocábulo teoria provém do grego theoria, que significa estudo, exame, designando a ação de contemplar, examinar. É o próprio conhecimento especulativo. Por teoria entendemos o conjunto de partes e princípios fundamentais de determinado ramo do conhecimento humano, buscando sua sistematização.

A teoria do direito, como o próprio nome determina, estuda todas as realidades do direito, buscando sua sistematização. A teoria do direito é de cunho filosófico, na medida em que se preocupa com o conhecimento amplo e geral. Tem como fulcro o conhecimento amplo, geral e real da ciência jurídica, não apenas no seu aspecto dogmático. Investiga as estruturas lógicas da experiência jurídica, analisando as normas e os princípios gerais do direito, o conceito, a divisão e a natureza do direito, buscando concluir com a sistematização de todo o fenômeno jurídico

Conhecer direito é conhecer a natureza científica da ciência jurídica (epistemologia), o seu valor fundamental (axiologia) e sua inserção na sociedade (realidade social – sociologia), não se esquecendo da ciência dogmática ou dogmática jurídica ou do direito, como preferimos, que se divide em estudo da norma agendi (estudo da norma) e facultas agendi (estudo dos direitos subjetivos).

Em resumo, a teoria do direito busca o conhecimento que no campo científico-jurídico se dá por intermédio do estudo da dogmática, sociologia e filosofia. Dessa forma, segundo nosso entendimento, a realidade jurídica e consequentemente a teoria do direito pode ser vislumbrada em três planos: dogmático, sociológico e filosófico.

1 O QUE É O DIREITO

O estudo da teoria do direito requer uma indagação preliminar: O que é o direito? A palavra direito não tem apenas um significado, sendo empregada em vários sentidos ou acepções.

Na linguagem comum e científica, o vocábulo direito é empregado com significações diferentes. A doutrina distingue dois sentidos fundamentais da palavra direito: 1. o direito norma, lei ou regra de ação (norma agendi); e 2. o direito faculdade, poder de ação, prerrogativa (facultas agendi)

Rudolf Von Ihering em sua obra “A Luta pelo Direito”, prescreve que a palavra direito emprega-se num duplo sentido: no sentido objetivo e no sentido subjetivo. O direito no sentido objetivo é o conjunto de princípios jurídicos aplicados pelo Estado à ordem legal da vida. O direito no sentido subjetivo é a transfusão da regra abstrata no direito concreto da pessoa interessada

Para Thomas Marky “o termo direito, entre outros, tem dois sentidos técnicos. Significa, primeiramente, a norma agendi, a regra jurídica. Assim, falamos de direito romano, de direito civil

brasileiro, como complexo de normas. Noutra acepção, a palavra significa a facultas agendi, que é o poder de exigir um comportamento alheio. Assim, a entendemos quando falamos em ‘direito à nossa casa’, ‘direito aos filhos’, ‘direito à remuneração do nosso trabalho’. No primeiro sentido, trata-se do direito objetivo e no segundo, do direito subjetivo”

Paulo Dourado de Gusmão alude que, de modo muito amplo, pode-se dizer que a palavra direito tem três sentidos:

1. regra de conduta obrigatória (direito objetivo);

2. sistemas de conhecimentos jurídicos (ciência do direito);

3. faculdade ou poderes que tem ou pode ter uma pessoa, ou seja, o que pode uma pessoa exigir de outra (direito subjetivo)

Miguel Reale, ao tratar das acepções da palavra direito, concluindo pela estrutura tridimensional do direito, entende que “uma análise em profundidade dos diversos sentidos da palavra Direito veio demonstrar que eles correspondem a três aspectos básicos, discerníveis em todo e qualquer momento da vida jurídica: um aspecto normativo (o Direito como ordenamento e sua respectiva ciência); um aspecto fático (o Direito como fato, ou em sua efetividade social e histórica) e um aspecto axiológico (o Direito como valor de Justiça)”.6 Assim, para o citado autor, havendo um fenômeno jurídico, há um fato subjacente (fato econômico, geográfico, demográfico etc.); um valor, que é conferido ao referido fato, e uma norma ou regra que integra o fato ao valor. Dessa forma, os três elementos (fato, valor e norma) coexistem numa unidade concreta.

Por meio de uma pesquisa mais rigorosa, André Franco Montoro, em seu livro Introdução à Ciência do Direito, destaca cinco realidades fundamentais,7 dentro da pluralidade de significações do direito no sentido científico jurídico:

1. o direito norma;

2. o direito faculdade;

3. o direito justo;

4. o direito ciência;

5. o direito fato social.

A palavra direito tem sentido nitidamente diverso nas seguintes expressões:

1. o direito brasileiro pune o crime de estupro;

2. o locador tem o direito de cobrar o aluguel;

3. o salário é direito do trabalhador;

4. o estudo do direito requer método próprio;

5. o direito é um setor da realidade social.

Ao atentarmos para a significação do vocábulo direito no sentido empregado em cada uma das referidas frases, verificamos nítidas diferenças. Assim, no primeiro caso, "direito" significa a norma jurídica, a lei, a regra social obrigatória (Norma). Na segunda expressão, "direito" significa a faculdade, o poder, a prerrogativa que o locador tem de cobrar o aluguel (Faculdade). Na terceira expressão, "direito" significa o que é devido por justiça (Justo). Ora, o trabalho sem remuneração é escravidão. A escravidão ofende os anseios da justiça. Na quarta expressão, "direito" significa ciência ou, mais exatamente, a ciência do direito (Ciência). Na última expressão, "direito" é considerado como fenômeno da vida coletiva. Ao lado dos fatos econômicos, artísticos, culturais e esportivos, também o direito é um fato social (Fato Social).

Cada realidade do direito dá origem a estudos sistemáticos, para que seja verificada de forma minuciosa cada uma das referidas significações, que na esteira de André Franco Montoro podem ser divididas em: 1. teoria da norma jurídica (norma); 2. teoria dos direitos subjetivos (faculdade); 3.epistemologia jurídica (ciência); 4. axiologia jurídica (justo); e 5. sociologia jurídica (realidade social).

Segundo nosso entendimento, o conhecimento do direito encontra-se em três planos: dogmático (norma), sociológico (fato) e filosófico (ciência e valor). Nesse sentido, a investigação da ciência do direito surge por meio do estudo da dogmática, sociologia e filosofia do direito. No contexto atual podemos identificar nesta sequência a influência do pós-positivismo, da sociedade da informação e do pós-modernismo.

2 DEFINIÇÃO DO DIREITO

Cremos que se encontra clara a resposta ao questionamento formulado: O que é o direito? Mas, o seu enunciado surgirá da definição de direito. Ora, o nosso objeto de estudo é o direito, havendo, pois, a necessidade de buscar a sua definição. Essa tarefa árdua pertence à filosofia, mais especificamente à epistemologia jurídica – (episteme) ciência e (logos) estudo – estudo da Ciência do Direito.

Como definir o Direito? Preliminarmente, o que é definir? A palavra definir vem do latim definitione, definire, que significa limitar. Assim, definir é limitar o objeto definido. "Definir é explicar o sentido de um vocábulo ou a natureza de uma coisa, ou ainda, é a operação que analisa a compreensão de um conceito".8 Para Aristóteles, a definição é a fórmula que exprime a essência de

uma coisa, sendo composta de gênero (próximo) e das diferenças (específicas). Marcus Cláudio Acquaviva ensina que "Definir é revelar a essência do objeto definido".9 Essência é tudo o que identifica o objeto a definir. Sem seus elementos essenciais, o ser ou a coisa careceriam de existência.

Na definição somente devem participar as causas essenciais do objeto definido, porque sem estas o objeto sequer existiria. Na configuração dos objetos e das coisas, existem causas essenciais e acidentais. Somente as causas essenciais devem figurar nas definições, sob pena de acidentalidade ou imprecisão. É nesse sentido que Aristóteles ensina que a definição perfeita consiste em exprimir a essência do objeto ou da coisa pelo gênero próximo e pela diferença específica. Tomemos como exemplo a definição de homem. O homem é o animal racional. Assim, para definir o homem utilizamos o gênero próximo "animal" e a diferença específica "racional". De outra feita, se definirmos o homem como o animal racional vivente, a definição torna-se imperfeita ou imprecisa, na medida em que o homem não é o único ser vivente. Não se trata de causa essencial. Ainda, se definirmos o homem como animal racional que usa óculos, a definição peca por acidentalidade, pois existem homens que não usam óculos.

Em resumo, definir é explicar o sentido de um vocábulo ou a natureza, a essência de uma coisa ou objeto. Dessa forma, segundo a lógica (Capítulo da Filosofia), há duas espécies de definições:

1. nominal; e

2. real.10

A definição nominal designa o que uma palavra ou nome significa, por meio da etimologia11 e da semântica.12 A definição real expressa o que é uma coisa ou realidade, indicando a natureza do objeto ou da coisa a ser definida.

Não existem dificuldades em estabelecer uma definição nominal da palavra direito. A palavra direito provém do latim directum, rectum, que significa direito, reto, aquilo que é conforme a uma régua, e sucessivamente, designando aquilo que é conforme a lei, a própria lei, conjunto de leis, ciência que tem por objeto as leis.13 O vocábulo latino directum, rectum apresenta variações semânticas em quase todas as línguas – Derecho (espanhol), Diritto (italiano), Droit (francês), Recht (alemão), Right (inglês), Dreptu (romeno), dret (catalão), ret (dinamarquês), rätt (sueco), rett (norueguês) e rétt (islandês).14

Ao lado da expressão directum, do baixo latim, existe a expressão jus do latim clássico, menos expressiva e suplantada pela primeira. O termo jus, ligado na origem jussum, significa direito, sendo representado por uma série de vocábulos: jurídico, jurisconsulto, judicial, judiciário, jurisprudência

etc. O termo jus designa ainda a ideia de poder, comando. Jubere é ordenar, mandar, comandar. Jus ou jussum é aquilo que é ordenado. Em Roma havia o jus e o fas. O jus era o conjunto de normas formuladas pelos homens, destinadas a dar ordem à vida em sociedade; fas era o conjunto de normas de origem divina, religiosa, que regeriam as relações entre os homens e as divindades.15 Para os romanos o jus era o direito propriamente dito, apresentando sentido diverso de justitia, que significa Justiça, conceito que conhecemos, ou seja, a qualidade ou fundamento do direito. Justitia (Justiça) indica a ideia de justum (justo).

Quanto às origens do vocábulo direito, cabe ainda menção à palavra grega diké, que significa indicar. Não há, entretanto, nas línguas modernas, palavras vinculadas ao diké grego. Esse fato confirma a supremacia do direito romano sobre o direito moderno, ao lado da influência, quase nula, da cultura grega, nesse particular. Em outros setores, como na filosofia, nas artes e nas ciências especulativas, foi profunda a influência da cultura helênica. Mas, no campo do direito, quase nada encontramos que nos ligue à Grécia. A influência decisiva nesse campo foi de Roma. O gênio prático dos romanos contrasta com a sabedoria teórica dos gregos. No campo do pensamento puro os gregos foram notáveis. Pode-se dizer que não houve em Roma filósofo que mereça ser posto ao lado de Sócrates, Platão ou Aristóteles. Mas, do ponto de vista prático – e o direito se situa neste campo – os romanos foram insuperáveis. O monumento jurídico que eles deixaram à humanidade, o direito romano, comunicou-se até nós e ainda influi poderosamente no direito contemporâneo.16

Dessa forma, podemos concluir que a definição nominal de direito é aquilo que é conforme a regra. Assim, direito passou a ser sinônimo de regra, de norma obrigatória.

Estabelecer uma definição real do termo direito torna-se por demais difícil, na medida em que esse vocábulo apresenta várias realidades, sendo praticamente impossível estabelecer uma única definição que corresponda a essa diversidade.

A palavra direito apresenta, do ponto de vista jurídico, cinco acepções fundamentais, que correspondem a cada realidade distinta: norma, faculdade, ciência, justiça e fato social. Luiz Antonio Rizzatto Nunes conseguiu com muita propriedade resumir o que é o direito, conforme elencamos, ao ditar que "sob o aspecto etimológico é possível ligar o termo direito, dentre outros, a reto (do vocábulo em latim rectum), a mandar, ordenar (do latim jus, ligado na origem jussum), ou ao termo indicar (do grego diké). Observando o Direito à luz da realidade dos estudos jurídicos contemporâneos, pode-se vislumbrar que o termo direito comporta pelo menos as seguintes concepções: a de ciência, correspondente ao conjunto de regras próprias utilizadas pela Ciência do Direito; a de norma jurídica, como a Constituição e as demais leis e decretos, portarias etc.; a de poder ou prerrogativa, quando se diz que alguém tem a faculdade, o poder de exercer um direito; a de fato social, quando se verifica a

existência de regras vivas existentes no meio social; a de Justiça, que surge quando se percebe que certa situação é de direito porque é justa”

Segundo o nosso entendimento, o direito se exterioriza em três aspectos: dogmático, filosófico e sociológico. Assim, para compreender a realidade jurídica dividimos o nosso estudo em três partes: 1. dogmática do direito, 2. sociologia do direito e 3. filosofia do direito.

A dogmática do direito estuda a norma jurídica. Esse objeto é investigado sob o prisma da norma abstrata (norma) e o poder de invocar a regra (faculdade). Nesse sentido, a dogmática do direito é dividida em dois capítulos: teoria da norma jurídica e teoria dos direitos subjetivos. O primeiro capítulo estuda a norma jurídica e sua aplicação e a segunda parte se preocupa com o direito subjetivo.

A sociologia do direito investiga o direito como fato social. No estudo da sociologia, distinguimos diversas espécies de fenômenos sociais, como, por exemplo, os fatos religiosos, econômicos, culturais e, entre eles, o direito. O direito é um setor da vida social, devendo ser estudado sociologicamente. É dentro dessa perspectiva que se situa a sociologia do direito. Nesse prisma o direito é encarado como o conjunto das condições de existência e desenvolvimento da sociedade coativamente assegurados. O direito como fato social verifica-se por meio das regras que se encontram no seio da sociedade.

A filosofia do direito investiga os princípios fundamentais e a natureza científica do direito. Para atingir esse objetivo dividimos o estudo em dois capítulos: epistemologia jurídica e axiologia jurídica. A epistemologia jurídica tem por objeto a ciência do direito. O direito é um setor do conhecimento humano. O direito na acepção de ciência é a exposição sistematizada do fenômeno jurídico. A ciência do direito na prática é o conjunto sistematizado das regras e dos princípios jurídicos. A ciência do direito investiga e sistematiza o fenômeno jurídico, constituindo a própria ciência. A axiologia jurídica estuda os valores do direito, em especial a justiça. O direito é empregado no sentido do justo objetivo.

A teoria do direito surge da sistematização do estado atual do conhecimento jurídico.

Conhecimento da Ciência do Direito	Dogmática do Direito	Teoria da Norma Jurídica Teoria dos Direitos Subjetivos
	Sociologia do Direito	A Sociedade e o Direito O Direito como Fato Social (Sociologia Jurídica)
	Filosofia do Direito	Epistemologia Jurídica Axiologia Jurídica

Em suma:

II DOGMÁTICA DO DIREITO

1 INTRODUÇÃO À DOGMÁTICA DO DIREITO

A dogmática, do grego dokéin, significa ensinar, doutrinar, designando em seu sentido científico uma função diretiva combinada com uma função informativa, ao acentuar o aspecto resposta de uma investigação. Assim, a dogmática jurídica enquanto ciência apresenta uma faceta diretiva (norma) e outra investigativa (ciência).

"A Dogmática Jurídica é aquela parte da Ciência do Direito que estuda o direito enquanto norma. Não há qualquer questionamento sobre justiça ou aspectos político-sociais do direito: o que importa é o conjunto de normas posto. Estudam-se, assim, os elementos componentes deste conjunto e o funcionamento do todo. Trata-se de terreno altamente técnico".18

O objeto de estudo da Dogmática do Direito é a norma jurídica. Logo, esse estudo científico é verificado pela sistematização do fenômeno normativo. "A norma jurídica é a própria essência da Dogmática Jurídica, parte da Ciência do Direito que trata da sua sistematização".19

A palavra norma vem do latim norma (esquadro, régua), e revela, no campo da conduta humana, a diretriz de um comportamento socialmente estabelecido. A norma jurídica nada mais é do que o preceito de direito estabelecido pela sociedade e que num dado momento da dinâmica social transforma-se em conduta obrigatória. A conduta social estabelecida como obrigatória é erigida à categoria de norma jurídica, é a lei. A norma jurídica (praeceptum juris) é o preceito de direito transformado em lei, e que comumente denominamos de direito. A norma é comando (praeceptum) e não um conselho (consilium).

O direito no sentido dogmático pode ser vislumbrado em dois sentidos fundamentais: norma e faculdade.

1.1 Direito Norma

O direito norma significa a lei, a regra social obrigatória. Vários autores o denominam como o aspecto primordial do direito, em oposição ao direito subjetivo. Assim, o direito norma é a "regra social obrigatória"20 ou a regra social obrigatória garantida pelo Estado.

O direito na acepção de norma apresenta, ainda, significados e realidades diversas, quando se refere:

1. ao direito estatal e ao direito não estatal;

2. ao direito positivo e ao direito natural;

3. à ordem ou ao sistema jurídico (direito objetivo, direito positivo).

Alguns autores dividem o direito norma em direito objetivo e subjetivo. Entretanto, conforme verificamos, o direito subjetivo diz respeito ao direito faculdade.

Preliminarmente, podemos dividir o direito norma em direito estatal e direito não estatal, também chamado de direito grupal ou direito social. O direito estatal confunde-se com a ideia de direito positivo, que se contrapõe ao direito natural. Cabe examinarmos, neste tópico, o que seja direito estatal e direito não estatal, direito positivo e direito natural e o sistema jurídico, no qual estão inseridos o direito objetivo e o direito positivo e, ainda, segundo o nosso entendimento do direito natural.

1.1.1 Direito Estatal e Direito Não Estatal

Entende-se por direito estatal as regras jurídicas emanadas do Estado, com a finalidade de reger a vida social (Constituição, Código Penal e Código Civil). Mas, ao lado do direito estatal, caminha o direito não estatal, que são as normas obrigatórias elaboradas por diferentes grupos sociais particulares institucionalizados e destinadas a reger a vida interna corporis desses grupos (Direito Universitário, Direito Religioso e Direito Esportivo). O direito estatal é dirigido a toda a coletividade, ao passo que o direito não estatal é dirigido aos membros de determinado grupo social particular institucionalizado.

1.1.2 Direito Positivo e Direito Natural

Toda a tradição do pensamento jurídico é dominado pela distinção entre o direito positivo e o direito natural. Das referidas locuções surgem duas principais maneiras de encarar o mundo jurídico: o positivismo e o naturalismo jurídico. Em linhas gerais, o jusnaturalismo ou naturalismo jurídico considera o direito natural como superior ao direito positivo. O direito natural prevalece sobre o direito positivo sempre que entre ambos ocorrer um conflito. Para o positivismo jurídico não existe outro direito senão o positivo. O positivismo jurídico, ao excluir o direito natural, procura reconhecer o direito positivo como o único direito vigente, limitando o estudo científico-jurídico ao estudo das legislações positivas.

A dicotomia entre direito positivo e natural pode ser tida como antiga. Para alguns, na acepção do direito romano, o direito natural (jus naturale) era o direito comum a todos os homens e animais, em oposição ao jus gentium, que era o direito comum a todos os homens. Em Roma o direito natural era aquilo que a natureza ensina aos seres. Ulpiano afirmou que o direito natural era aquilo que a natureza ensinava aos homens e aos animais (ius naturale est quod natura omnia animalia docuit) e o direito das gentes, aquele comum a todos os povos (ius gentium est quo gentes humanae utuntur). No latim da época romana verifica-se o termo positivus empregado em sentido análogo de direito positivo. Na verdade a doutrina aponta a trilogia existente em Roma: jus naturale (direito natural), jus gentium (direito das gentes) e jus civile (direito do cidadão). Nessa esteira, o direito natural

correspondia ao jus gentium (direito comum a todos os homens) em contraposição ao jus civile (direito dos cidadãos romanos), correspondente ao nosso conceito de direito positivo.21 Neste sentido, o Digesto de Justiniano fazia referência ao direito natural (ius naturale), ao direito das gentes (ius gentium) e ao direito civil (ius civile).22

"O jus gentium e os jus civile correspondem à nossa distinção entre direito natural e direito positivo, visto que o primeiro se refere à natureza (naturalis ratio) e o segundo, às estatuições do populus. Das distinções ora apresentadas, temos que são dois os critérios para distinguir o direito positivo (jus civile) do direito natural (jus gentium): a) o primeiro limita-se a um determinado povo, ao passo que o segundo não tem limites; b) o primeiro é posto pelo povo (isto é, por uma entidade social criada pelos homens), enquanto o segundo é posto pela naturalis ratio".23

Nas Institutas de Gaio não havia a classificação tricotômica, mas uma dicotomia, em que ao jus civile se contrapunha ao jus naturale, confundido com o jus gentium. Assim, podemos afirmar que para o Direito Romano o direito natural era o jus naturale e o jus gentium, o direito conhecido por todos os povos, em oposição ao jus civile, ou seja, aquele direito posto e imposto pelo Estado.

Cícero encarava o direito natural como uma norma jurídica, dotada de obrigatoriedade pela natureza, universal, imutável e eterna (Est quaedam vera lex, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna).

No Direito Romano já se verificava uma série de interditos, que tinha como finalidade tutelar os direitos individuais em face do direito estatal.

A Lei das Doze Tábuas, como texto escrito, já consagrava a liberdade, a propriedade e a proteção de direitos individuais.

No mundo grego havia a distinção entre aquilo que é natural (physis) e aquilo que é estabelecido por convenção humana (thésis). Na Grécia houve o desenvolvimento das ideias de um direito natural e de direitos humanos básicos, como a participação política dos cidadãos (democracia direta de Péricles). Já se despontava a existência de um direito natural no pensamento dos sofistas24 e estoicos,25 como, por exemplo, o dramaturgo Sófocles, que na obra Antígona (441 a.C.) defende a existência de normas superiores e imutáveis, ou seja, a existência de um direito natural.26 Heráclito de Éfeso encarou a natureza em seu aspecto dinâmico, afirmando que todas as leis encontram seu fundamento na lei divina, surgindo uma norma universal, imutável e eterna.

Platão vislumbrava a lei natural como fonte de produção da lei positiva. Para Aristóteles, se a lei positiva não consagra a justiça, deve-se buscar a lei natural e a equidade. Na Retórica, Aristóteles

estabelece uma distinção entre lei particular e lei comum. A primeira é aquela inerente a cada povo. A segunda é aquela comum a todos, conforme a natureza.

No judaísmo verifica-se a existência de lei comum a todos, que se estabelecia com as alianças que Deus celebrou com seu povo (Alianças com Noé, Abraão, Isaque e Jacó). No cristianismo surge a ideia de que todos são chamados, não havendo distinção entre os gentios, judeus e gregos.27 Dessa feita, na cultura judaico-cristã se verifica a existência de uma lei natural.

Na Idade Média o direito natural passou a confundir-se, sob a influência da teologia, com a moral, cuja origem era a Lei Divina. O direito natural era o contido na Lei Mosaica e nos Evangelhos.28 A própria lei escrita por Deus no coração dos homens. Nessa época, o direito natural passou a ser considerado superior ao positivo, na medida em que não era mais visto como um simples direito comum, mas como norma fundada na vontade divina. Desta visão teológica do direito natural derivou a tendência permanente no pensamento jusnaturalista, de considerar o direito natural superior ao direito positivo, em oposição ao positivismo jurídico, que considera que não existe outro direito senão o positivado.

Santo Agostinho pregava a existência do direito natural fundado por Deus, imutável e universal. Esse teólogo afirmava a existência de duas leis:

1. lex aeterna – lei divina; e

2. lex temporalis – direito positivo.

Segundo Tomás de Aquino, em sua Summa Theologica, existem três espécies de leis:

1. lex aeterna – a lei da razão divina;

2. lex naturalis – a lei natural; e

3. lex humana – a lei do homem.

Para John Locke, todos os homens possuem, por natureza, os direitos inerentes, devendo o Estado apenas tutelar tais prerrogativas naturais por intermédio do direito positivo. Dessa forma, podemos distinguir o direito natural do direito positivo, como sendo o primeiro os direitos inatos ao homem e, o segundo, os direitos adquiridos.

Modernamente, o direito natural pode ser entendido como fundamento ao direito positivo, tais como: “dar a cada um o que é seu”, “não lesar ninguém”, “viver honestamente”, “deve se fazer o bem” etc. Nesse sentido, lembramos das expressões honeste vivere (viver honestamente); alterum non laedere (não lesar ninguém); suum cuique tribuere (dar a cada um o que é seu), que são princípios formulados na Instituta de Justiniano, considerada como a definição romana de Direito.29

Segundo nosso entendimento, o direito natural é o conjunto mínimo de preceitos dotados de caráter universal, imutável, que surge da natureza humana e que se configura como um dos princípios de legitimidade do direito. Os direitos naturais são inerentes ao indivíduo, devem estar em qualquer sociedade e precedem a formação do Estado e do direito positivo.

Ante as várias concepções estabelecidas na dicotomia direito positivo e direito natural, podemos estabelecer as principais distinções:

1. O direito natural é universal (tem eficácia em qualquer parte). O direito positivo é singular ou particular à sociedade política de que surge (tem eficácia em determinado local).

2. O direito natural é imutável (no tempo e no espaço). O direito positivo é mutável (no tempo e no espaço). Cabe aqui anotar que alguns entendem que o direito natural pode mudar com o tempo.

3. O direito natural surge da natureza humana, por intermédio da razão, intuição ou da revelação. Por isso, se afirma que o direito natural é dado e não estabelecido por normas ou estatutos. O direito positivo surge do Estado.

Das referidas assertivas, extraímos as características fundamentais do jusnaturalismo:

1. A origem dos direitos do homem não é o direito positivo, mas uma ordem jurídica superior e suprema, denominada direito natural.

2. Os direitos naturais são a expressão da natureza humana presente em todos os membros da família humana (comum e universal); não é uma concessão graciosa do direito positivo.

3. O direito natural existe independentemente de ser reconhecido ou respeitado pelo direito positivo.30

O direito positivo é o conjunto de normas estatais em vigor em determinado país numa determinada época. Representa o regime da vida social corrente. É o direito posto, imposto, positivado pelo Estado. O direito natural é o ordenamento ideal correspondente a uma justiça superior e suprema. É o conjunto de princípios preexistentes e dominantes. “O adjetivo natural, aplicado a um conjunto de normas, já evidencia o sentido da expressão, qual seja, o de preceitos de convivência criados pela própria Natureza e que, portanto, precederiam a lei escrita ou o direito positivo, normas postas, impostas pelo Estado (jus positum)”.31 O direito natural é constituído pelos princípios que servem de fundamento ao direito positivo. São os preceitos de convivência criados pela própria natureza e que, portanto, precedem o direito positivo. Na história verifica-se claramente que os sistemas jurídicos que não foram embasados no direito natural trouxeram consequências desastrosas. O reconhecimento do direito natural não implica a exclusão de outros fatores e valores sociais que influenciam a realidade jurídica, que verificaremos no estudo da sociologia.

1.1.3 Ordem Jurídica

Entende-se por Ordem Jurídica o conjunto de todas as normas em vigor no Estado, completadas pelas técnicas de interpretação e integração do direito. A ordem jurídica pode ser definida como o conjunto harmônico de normas jurídicas vigentes em dado momento histórico, numa sociedade determinada. Podemos afirmar que, nesse ponto, confundimos ordem jurídica com sistema jurídico, trazendo ao conceito não apenas as normas legislativas estatais, mas também o direito não estatal, bem como as normas consuetudinárias, a jurisprudência, ou seja, os princípios gerais do direito, vigentes em determinado momento histórico, como, por exemplo, Ordem Jurídica da Roma Antiga, Sistema Jurídico Norte-Americano.

O vocábulo ordem, do latim ordine, apresenta radical or, designando diretriz, rumo a seguir. Ordem pode ser conceituada como a unidade na multiplicidade ou a conveniente disposição de elementos para realização de um fim. Na ordem jurídica verificamos uma estrutura escalonada de normas que formam uma unidade. As normas formam um sistema que se reduz a uma unidade. Nessa esteira, a definição de Paulo Nader, "Ordem Jurídica é expressão que coloca em destaque uma das qualidades essenciais do Direito Positivo, que é a de agrupar normas que se ajustam entre si e formam um todo harmônico e coerente de preceitos".32

O nosso sistema jurídico é hierarquizado, verificando-se normas superiores e inferiores. As normas de hierarquia inferior não podem ampliar os termos da norma superior. As normas jurídicas se encadeiam dando origem a um complexo sistema normativo. Este sistema é escalonado, ou seja, as normas jurídicas apresentam-se hierarquicamente dentro do sistema jurídico ou da ordem jurídica. Forma-se uma pirâmide jurídica, em que na base estão as normas contratuais, declarações unilaterais de vontade e outros documentos particulares até a Constituição Federal que se encontra no ápice. A validade de cada norma é verificada pela compatibilidade com o preceito superior hierarquicamente.

Nesse sentido a doutrina de Hans Kelsen, que construiu a ideia de que não pode haver conflito entre a norma de escalão superior e uma norma de escalão inferior, pois esta possui seu fundamento de validade na norma superior. Assim, se a norma hierarquicamente inferior é válida, pressupõe-se que se encontra em harmonia com norma superior.33

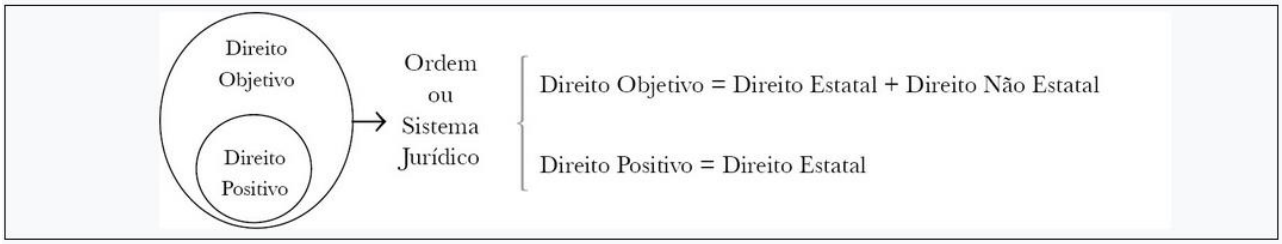
Celso Bastos, sobre a matéria, diz que "aquelas normas que fundam outras normas ganham uma posição de superioridade, de preeminência, resultando no fato de as normas subordinadas, as que delas tiram seu fundamento, não as poderem contrariar: as normas inferiores têm que estar em consonância com as superiores. Se tal não ocorre, elas deixam de possuir validade em face do ordenamento jurídico".34

Cabe anotar que o conjunto uniforme de regras e princípios jurídicos, com a finalidade de reger determinada matéria, forma um instituto jurídico. O instituto jurídico é o estudo sistemático de parte do ordenamento jurídico, que devido à sua importância no meio social é enfocado pelos estudiosos e operadores do direito. Ex.: União Estável, Propriedade e Direitos da Personalidade. Paulo Nader anota que "o Instituto Jurídico é a reunião de normas jurídicas afins, que rege um tipo de relação social ou interesse e que se identifica pelo fim que procura realizar. É uma parte da ordem jurídica. Diversos institutos afins formam um ramo, e o conjunto destes, a ordem jurídica".35

Dentro do sistema jurídico vislumbramos a existência do direito objetivo e do direito positivo. O direito objetivo é o conjunto de todas as normas em vigor no Estado. Abrange as normas de direito estatal e não estatal. O direito positivo é o conjunto das normas em vigor e emanadas pelo Estado. O direito positivo é o direito posto, imposto, positivo. O direito positivo é o direito imposto pelo Estado, podendo ser promulgado (legislação) ou declarado (precedente judicial, direito anglo-americano). É o direito institucionalizado pelo Estado por meio de sua chancela. Paulo Dourado de Gusmão ensina que "o Direito Positivo é o direito histórico e objetivamente estabelecido, efetivamente observado ou, então, passível de ser imposto coercitivamente".36

José Geraldo Brito Filomeno ensina que "o ordenamento jurídico não deve ser confundido com uma só norma, como, por exemplo, a Constituição de um determinado Estado, mas sim o conjunto de normas por ele ditadas e de variedade complexa e abrangente. O direito positivo é aquele que é revelado, posto, pelo Estado, por intermédio de seus órgãos competentes. Direito objetivo, a seu turno, vem a ser o conjunto de todas as normas constitutivas e comportamentais em geral, quer oriundas do Estado, quer das sociedades comuns ou contingentes".37

Podemos estabelecer o seguinte quadro:



1.2 Direito Faculdade

O direito faculdade nada mais é do que o direito subjetivo. O vocábulo direito com frequência é empregado para designar o poder de uma pessoa, individual ou coletiva, em relação a determinado objeto. É uma prerrogativa ou faculdade de agir. É a facultas agendi, em oposição ao direito-lei ou norma, que é a norma agendi. Assim, o direito faculdade é a prerrogativa concedida pela lei. No dizer de Goffredo Telles Junior, é a norma autorizante, ou seja, a autorização concedida pela norma para

que o sujeito possa agir: “Os direitos subjetivos se definem: permissões dadas por meio de normas jurídicas. São autorizações, fundadas no direito objetivo, para uso das faculdades humanas. O que caracteriza e distingue é, precisamente, o meio pelo qual as permissões são dadas. Por serem dadas por meio de normas jurídicas, essas permissões são permissões jurídicas. Logo, os direitos subjetivos podem também ser definidos com estas precisas palavras: permissões jurídicas. (...) Em suma, uma permissão só é jurídica quando ela é dada por meio de norma autorizante. A norma autorizante é o instrumento pelo qual são outorgadas as autorizações constitutivas dos direitos subjetivos”.38

1.2.1 A Relação entre Direito Objetivo e Direito Subjetivo

O direito objetivo é a norma jurídica (norma agendi). O direito subjetivo é a faculdade do titular da norma. É o próprio direito faculdade (facultas agendi). O direito subjetivo é o reconhecimento pelo direito objetivo de um interesse, seja ele qual for. O direito subjetivo é a faculdade, a prerrogativa concedida pelo direito objetivo. A expressão direito subjetivo se explica e se justifica, porque o direito nessa acepção é realmente um poder do sujeito. É uma faculdade reconhecida ao sujeito ou titular do direito. É a possibilidade de agir. O art. 70 do Código de Processo Civil reza que “Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo”. Esse é um exemplo de direito subjetivo, ou seja, a faculdade que o Código de Processo Civil confere a alguém para fazer valer um direito de que é titular.

O direito objetivo é a regra. O direito subjetivo é a transfusão da regra abstrata no direito concreto de cada pessoa.

1.3 Objeto de Estudo da Dogmática do Direito

O objeto de estudo da dogmática do direito, conforme afirmamos, é a norma jurídica. Esta pode ser vislumbrada de duas formas: norma e faculdade. Assim, a investigação dogmática pode ser dividida em dois capítulos: Teoria da Norma Jurídica e Teoria dos Direitos Subjetivos.

Na Teoria da Norma Jurídica a investigação recai sobre a norma abstrata e consequentemente sua interpretação e aplicação. Na Teoria dos Direitos Subjetivos a preocupação encontra-se nos direitos subjetivos.

2 TEORIA DA NORMA JURÍDICA

A Teoria da Norma Jurídica preocupa-se precipuamente com a norma jurídica, sua interpretação e aplicação. A investigação parte do preceito abstrato que é o direito objetivo. O direito se forma e se manifesta na vida social, sendo certo que existem dois momentos fundamentais na gênese do direito: o de sua “formação” e o de sua “manifestação”.

Aí já verificamos o primeiro ponto de contato com a Sociologia Genética do Direito, pois o direito nasce da sociedade, sendo resultado de um complexo de fatores e valores sociais. Conforme

assevera André Franco Montoro, “o direito emana da sociedade sob múltiplos aspectos: 1. como resultado do poder social; 2. como reflexo dos objetivos, valores e necessidades sociais; 3. como manifestação ou efeito de fatores sociais: históricos, geográficos, técnicos, econômicos, culturais, psicológicos, morais e religiosos etc.”.39

Dessa forma, podemos concluir que na formação do conteúdo das normas concorre todo um conjunto de fatores e valores sociais. No que tange à manifestação do direito, o mesmo surge na vida social através de certos meios ou formas de manifestação ou expressão: a legislação, o costume jurídico, a jurisprudência. A partir dessa premissa, o ponto de partida do estudo da Teoria da Norma Jurídica é o que a doutrina denomina Fontes do Direito.

3 FONTES DO DIREITO

3.1 Conceito

A palavra fonte deriva do latim fons, fontins, que significa nascente, designando tudo o que origina, produz algo. A expressão fontes do direito trata-se de uma metáfora, para designar a própria gênese do direito, pois em sentido próprio fonte é a nascente de que brota uma corrente de água. Assim, a expressão “fontes do direito” denomina as próprias origens, causas do direito positivo. Maria Helena Diniz anota que “fonte jurídica seria a origem primária do direito, confundindo-se com o problema da gênese do direito. Trata-se da fonte real ou material do direito, ou seja, dos fatores reais que condicionaram o aparecimento de norma jurídica”.40

Segundo a definição de José Cretella Júnior as “fontes do direito são os diversos modos de formação do direito, significando toda a espécie de documento ou monumento que serve para revelar o direito”.41 Nesse sentido, fonte do direito é todo o modo de formação do direito, todo o documento, monumento, pessoa, órgão ou fato donde provém a norma jurídica.

Em termos técnico-jurídicos “são fontes do direito aqueles fatos ou aqueles atos aos quais um determinado ordenamento jurídico atribui a competência ou a capacidade de produzir normas jurídicas”.42

3.2 Teoria das Fontes do Direito

O estudo da Dogmática do Direito está intimamente ligado às fontes do direito, na medida em que a validade das normas jurídicas encontra-se aliada ao problema das fontes do direito. Assim, uma norma jurídica é tida como válida quando surge de fatos ou atos competentes ou capazes de produzir normas jurídicas, segundo o sistema jurídico. A validade e a existência da norma jurídica dependem do reconhecimento da fonte pelo sistema jurídico. O fundamento da norma jurídica encontra-se na fonte de que ela promana.

Norberto Bobbio ensina que “os ordenamentos jurídicos que atingiram certa complexidade e certa maturidade, como os modernos, estabelecem eles mesmos quais são as fontes do direito, o que significa que estabelecem os critérios de validade das próprias normas”.43 Os citados sistemas jurídicos não contêm apenas normas que regulam o comportamento dos membros da sociedade, mas também normas que regulam a produção jurídica. A doutrina jurídica distingue essas duas categorias de normas, qualificando-as respectivamente como regras de comportamento e como regras de estrutura ou de organização.

O positivismo jurídico reduz o direito a um conjunto de normas emanadas do Estado. Dessa forma, o Estado seria a única fonte do direito, vez que as fontes da norma jurídica são unicamente aquelas elaboradas e formalizadas pelos órgãos do Poder Público. Nessa concepção, o problema das fontes do direito pode ser simplificado, afirmando, dogmaticamente, que o Estado é a única fonte do direito.

Parte da doutrina juspositivista é baseada no princípio da prevalência de uma determinada fonte do direito, ou seja, aquela que emana diretamente do Estado (lei) sobre todas as outras. Para que seja verificada a referida possibilidade, urge a necessidade de duas condições: 1. sistema jurídico complexo; e 2. sistema jurídico hierarquicamente estruturado.

O sistema jurídico simples é aquele que possui uma única fonte de produção do direito. O sistema jurídico complexo é aquele que possui várias fontes de produção do direito. Ainda, o sistema jurídico é hierarquicamente estruturado, na medida em que encontramos fontes que estão dispostas hierarquicamente subordinadas umas às outras.

A doutrina juspositivista ao estudar as fontes do direito vislumbra a existência de um sistema jurídico complexo e hierarquizado, entendendo que a fonte que se encontra no plano hierárquico mais alto é a lei, pois esta é a manifestação direta do poder soberano do Estado e que os outros fatos ou atos produtores de normas são apenas fontes subordinadas.

Para o positivismo, as fontes subordinadas são fontes de conhecimento jurídico e as hierarquicamente superiores são fontes de qualificação jurídica. Assim, parte do positivismo jurídico admite uma pluralidade de fontes, entretanto, fundamentam essa assertiva, ponderando pela existência de uma pluralidade de fontes de conhecimento, sustentando a existência de uma única fonte de qualificação e identifica esta última com aquela que emana do Estado (lei).

Em que pese o esforço do positivismo jurídico, não há como negar a existência da pluralidade de fontes no sistema jurídico, não havendo como reduzir sua importância no mundo jurídico.

Assim, a importância do problema das fontes do direito é uma realidade solar, vez que constitui o ponto de estudo da filosofia e da sociologia do direito, e constitui objeto crucial de toda reflexão jurídica, em especial o estudo da dogmática do direito.

3.3 Espécies de Fontes do Direito

Segundo Marcus Cláudio Acquaviva, a doutrina tradicional enumera três espécies de fontes do direito: 1. fontes materiais; 2. fontes históricas; e 3. fontes formais.44

As fontes materiais são todos os fatores sociais representados pelas necessidades políticas, econômicas e culturais, bem assim fatores naturais, como o clima e o relevo. Constituem a matéria-prima da elaboração do direito.

As fontes históricas são todos os documentos jurídicos e coleções legislativas do passado que, devido à sua importância e sabedoria, continuam a influenciar as legislações do presente, como, por exemplo, a Lei das Doze Tábuas, o Código de Hamurábi.

As fontes formais são a lei, os costumes, a doutrina e a jurisprudência.

André Franco Montoro ensina que "os autores costumam distinguir as fontes formais, isto é, os fatos que dão a uma regra o caráter de direito positivo e obrigatório, das fontes materiais, representadas pelos elementos que concorrem para a formação do conteúdo ou matéria da norma jurídica. Como fontes formais do direito, indicam-se tradicionalmente: a) a legislação; b) o costume jurídico; c) a jurisprudência; d) a doutrina. Como fontes materiais podem ser mencionadas: a) a realidade social, isto é, o conjunto de fatos sociais que contribuem para a formação do conteúdo do direito; b) os valores que o direito procura realizar, fundamentalmente sintetizados no conceito amplo de justiça".45

Para a maioria dos doutrinadores, duas são as classes de fontes do direito: 1. fontes de produção, materiais ou substanciais; e 2. fontes de conhecimento, cognição ou formais.

Como fonte de produção, é colocada basicamente o Estado. Cabe anotar, entretanto, que o Estado não legisla arbitrariamente ou em causa própria. É a vida social por meio dos valores e fatores sociais, que impulsionam o ditar do direito. Outra importante fonte de produção do direito são os "grupos sociais particulares". São as chamadas fontes de direito não estatal, que surge dos anseios do "grupo social particular". As fontes formais revelam o direito, sendo a maneira pela qual a norma se exterioriza e se objetiva.

"A fonte material ou real aponta a origem do direito, configurando sua gênese, daí ser fonte de produção, aludindo a fatores éticos, sociológicos, históricos, políticos etc., que produzem o direito, condicionam o seu desenvolvimento e determinam o conteúdo das normas. A fonte formal lhe dá

forma, fazendo referência aos modos de manifestação das normas jurídicas, demonstrando quais os meios empregados pelo jurista para conhecer o direito, ao indicar os documentos que revelam o direito vigente, possibilitando sua aplicação a casos concretos, apresentando-se, portanto, como fonte cognição. As fontes formais são os modos de manifestação do direito mediante os quais o jurista conhece e descreve o fenômeno jurídico. Logo, quem quiser conhecer o direito, deverá buscar a informação desejada nas suas fontes formais, ou seja, na lei, nos arquivos de jurisprudência, nos tratados doutrinários. O órgão aplicador, por sua vez, também recorre a elas, invocando-as como justificação da sua norma individual".46

Parte da doutrina divide as fontes formais em mediatas e imediatas. Como fonte imediata, grande número de autores aponta a lei e o costume. Fontes mediatas são a doutrina e jurisprudência. Dessa forma, pode ser estabelecido, com fulcro na doutrina tradicional, o seguinte quadro:

Na verdade podemos estabelecer a seguinte divisão para as fontes do direito:

- Fontes do Direito
  - Materiais
    - Estado → Fatores e Valores Sociais
    - Grupos Sociais Particulares → Anseios do Grupo
  - Formais
    - Imediatas ou Primárias
      - Lei
      - Costume
    - Mediatas ou Secundárias
      - Jurisprudência
      - Doutrina

3.4 As Fontes Não Estatais

O direito contemporâneo concluiu que o Estado não detém o monopólio da elaboração das normas jurídicas, visto que estas emergem dos vários grupos sociais particulares contidos no Estado, muito embora limitado em seu âmbito.

Nesse prisma, no estudo das fontes do direito, deve ser ressaltado o poder normativo dos grupos sociais particulares, que nos dias de hoje se configuram como uma realidade solar. Assim, existem vários ordenamentos jurídicos, sendo certo que cada grupo social particular possui normas próprias. Esses grupos sociais são fontes de normas, pois têm o poder de criar suas próprias ordenações jurídicas que garantem a consecução dos fins que pretendem atingir.

Conforme anota André Franco Montoro, "ao lado das normas jurídicas elaboradas pelo Estado, existem outras normas efetivamente obrigatórias e exigíveis, de origem não estatal. São elaboradas pelos diferentes grupos sociais e destinadas a reger a vida interna desses grupos. Esses ordenamentos jurídicos, elaborados por diferentes grupos sociais e não pelo Estado, constituem

também fontes do direito, embora em caráter subsidiário e, em regra, desde que não colidam com a legislação em vigor".47

Nessa esteira de pensamento, salutar o ensinamento de Maria Helena Diniz, ao explicar que "vários são os grupos, mas todos pertencem a uma sociedade global, que é a sociedade política; múltiplas são as ordenações jurídicas (direito estatutário, direito esportivo e direito religioso), mas todas são vistas como partes de uma mesma ordem jurídica. Assim sendo, é necessário que as normas dos agrupamentos sociais ocupem um lugar apropriado no ordenamento jurídico da sociedade política. Uma norma só terá juridicidade se estiver apoiada na ordenação da sociedade política; portanto o Estado desempenha o papel de fator de unidade normativa da nação. De um lado se tem um pluralismo de ordenações jurídicas e, de outro, a unidade da ordem normativa".48

Dessa forma, podemos concluir que os grupos sociais particulares possuem um poder normativo, sendo certo que o Estado não é o único criador e elaborador de normas. Os grupos sociais particulares, como a Igreja, Sindicato, Clubes, Universidades etc., estabelecem ordenamentos jurídicos próprios, desde que coesos com a ordem jurídica do Estado. Como exemplo de ordenamentos jurídicos dos grupos sociais particulares, podemos citar: 1. o direito estatutário; 2. o direito esportivo; 3. o direito social nas relações de trabalho; 4. o direito religioso ou eclesiástico; e 5. o direito costumeiro das relações internacionais.

Parte da doutrina não admite os ordenamentos jurídicos como manifestação de direito. É a chamada tese do "monismo jurídico", que nega aos ordenamentos não elaborados pelos Estados, qualquer caráter jurídico. Para os doutrinadores filiados ao monismo jurídico, só existe a ordem jurídica estatal. Em contrapartida, para os adeptos do "pluralismo jurídico", ao lado do direito estatal, existem normas não estatais, emanadas de grupos sociais particulares.

Em suma:

Monismo Jurídico → Direito Estatal

Pluralismo Jurídico { Direito Estatal / Direito Não Estatal

No sistema jurídico pátrio vislumbramos claramente o poder normativo dos grupos sociais particulares. Da leitura do texto constitucional de 1988, verificamos que o Estado acolhe expressamente as normas de direito não estatal, como, por exemplo:

1. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI); e

2. Autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento (art. 217, I). Ainda, nesse sentido, o sistema jurídico pátrio reconhece a Justiça desportiva não estatal, ao estabelecer que o Poder Judiciário Estatal só admitirá ações relativas à disciplina e às competições após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, reguladas em lei; e

3. Autonomia Universitária (art. 207).

3.5 Poder Negocial

A doutrina discute se o poder negocial pode ser uma fonte de direito. O contrato é o negócio jurídico típico. Assim, seria o contrato uma fonte de direito? O contrato não pode ser considerado como fonte de direito. O negócio jurídico produz efeitos entre as partes contratantes, ao passo que as fontes do direito são gerais e destinadas a um grupo de pessoas. Ainda, o contrato está adstrito a um caso concreto, enquanto as normas oriundas das fontes do direito se referem a casos in abstracto.

Dessa feita, a doutrina tradicional exclui o contrato e os negócios jurídicos das fontes do direito. Para outros autores, o negócio jurídico é uma fonte de direito, na medida em que o contrato produz uma norma entre as partes, e sendo este uma manifestação de vontade com o fim de produzir um resultado jurídico, constitui verdadeira fonte do direito. Nesse sentido Miguel Reale reconhece o poder negocial como fonte de normas jurídicas particulares e individuais que só vinculam os participantes da relação jurídica. "A experiência jurídica não é disciplinada somente por normas legais ou leis, de caráter genérico, mas também por normas particulares e individualizadas. Entre as normas particulares, assim chamadas por só ligarem os participantes da relação jurídica, estão as normas negociais e, dentre estas, por sua fundamental importância, as normas contratuais, comumente denominadas cláusulas contratuais."49

Para André Franco Montoro "os contratos, sentenças e atos semelhantes, não contendo disposições abstratas, gerais e permanentes, não participam da natureza da lei. Mas, por sua força e obrigatoriedade, possuem inegável caráter vinculatório e, nesse sentido, constituem normas ou regras de conduta normativa. Por isso, na linguagem jurídica, consagrou-se a expressão de que o contrato é lei entre as partes, do mesmo modo que a sentença é a lei viva, efetivamente aplicada ao caso concreto".50

Ante todo o exposto, forçoso concluir que na medida em que o contrato vincula apenas os participantes da relação jurídica contratual não se configura como uma verdadeira fonte do direito. Entretanto, essa assertiva não pode ser estabelecida em termos absolutos, pois a autonomia contratual, por vezes, impulsiona a formação e manifestação do direito.

4 LEI

Nas sociedades modernas, a lei é indiscutivelmente a mais importante das fontes formais do direito. Indubitavelmente, a lei é o instrumento básico para a solução dos problemas jurídicos, vez que fixa as linhas fundamentais de qualquer sistema jurídico.

4.1 Sentido e Acepções da Palavra Lei

Divergem os autores acerca da etimologia da palavra lei, sendo indicadas três origens latinas diferentes: 1. legere, que significa ler. A lei é norma escrita, aquilo que se lê, em oposição às normas costumeiras, que não são escritas; 2. ligare, que significa ligar, obrigar, vincular. A lei obriga ou liga as pessoas, a uma certa maneira de agir, é o liame entre as pessoas (como ocorre nos contratos); 3. eligere, eleger, escolher, porque a lei é a norma escolhida pelo legislador, entre os muitos preceitos sociais.

Em suma:

$$\text{Lei} \begin{cases} \textit{Legere} \rightarrow \text{Ler} \\ \textit{Ligare} \rightarrow \text{Ligar} \\ \textit{Eligere} \rightarrow \text{Eleger} \end{cases}$$

De outra feita, entendemos que o vocábulo lei apresenta duas acepções diferentes: física (natural ou descritiva) e cultural (humana ou normativa).

Na acepção física ou natural, o termo lei é empregado para designar qualquer relação causal, sendo aplicada no mundo da natureza. São as leis descritivas as leis físico-matemáticas. São as conhecidas fórmulas, que não são imperativas, mas indicativas ou descritivas, tendo por finalidade apenas descrever as leis ou os fenômenos da vida, que ocorrem diuturnamente, como, por exemplo, a lei da gravidade.

Na acepção cultural, o termo lei designa a norma que é posta pelo homem. A lei cultural pode ser de duas espécies: 1. as sociológicas, históricas, econômicas, fruto das ciências humanas, que não retratam tão somente a realidade, mas enunciam juízos de valor sobre ela; e 2. as leis éticas ou morais, ou seja, qualquer norma, incluindo as regras escritas ou costumeiras, que tem por finalidade regular o agir humano.

Dessa forma, podemos afirmar que o termo lei, tomado num sentido genérico, pode ser aplicado tanto no mundo da natureza, como no mundo da cultura, designando as leis físicas e as leis

sociais. É a lei, no sentido universal, as leis físico-matemáticas, as leis sociais e as leis éticas. Nessa esteira, os doutrinadores distinguem as leis causais da natureza das leis normativas ou normas, que exprimem deveres.51 Essas duas espécies de leis são manifestações diferentes de uma mesma ordem ou lei cósmica ou universal, ou seja, lei no sentido genérico.

Concluindo, podemos estabelecer que no sentido genérico verificam-se três espécies de leis: 1. leis físicas, que se encontram no plano explicativo; 2. leis culturais, que se encontram no plano compreensivo; 3. leis éticas, que se encontram no plano normativo.

Em suma:

Lei Universal – Sentido Genérico	Leis Físicas Leis Culturais Leis Éticas

Na acepção normativa, o termo lei designa a lei humana, ética ou moral, ou seja, qualquer norma, incluindo as regras escritas ou costumeiras. Nessa acepção, o termo lei apresenta quatro espécies. Entre as normas éticas que dirigem o comportamento humano, podemos mencionar: 1. normas religiosas; 2. normas morais; 3. normas de trato social (usos e costumes sociais); e 4. normas jurídicas.

No nosso estudo destacamos a lei jurídica, vez que é nessa acepção que se vislumbra a lei como fonte do direito.

A lei jurídica é empregada em três sentidos: latíssimo, lato e restrito ou técnico.

No sentido latíssimo, o vocábulo lei abrange todas as normas jurídicas, escritas ou costumeiras, como a lei escrita, costume jurídico, jurisprudência, normas negociais etc.

No sentido lato, o vocábulo lei é empregado como sinônimo de legislação, ou seja, para indicar regras jurídicas escritas, sejam as leis propriamente ditas, aquelas oriundas do Poder Legislativo, sejam os decretos, medidas provisórias ou outras normas baixadas pelo Poder Executivo.

No sentido técnico-jurídico, lei é apenas a norma jurídica aprovada regularmente pelo Poder Legislativo. Esta é a acepção estrita e própria da palavra lei.

Lei Jurídica – Norma Jurídica	Sentido Latíssimo – Norma Jurídica Sentido Lato – Legislação Sentido Restrito e Próprio – Lei

4.2 Definição de Lei Jurídica

Em sentido amplo a lei jurídica é definida por François Gény como a "norma de conduta do homem com seus semelhantes, garantida pela eventual aplicação da força social, tendo em vista a justiça".52

Para o jurista italiano Giorgio Del Vecchio, "lei é o pensamento jurídico deliberado e consciente, expresso por órgãos adequados que representam a vontade preponderante". 53

A lei em sentido estrito e próprio pode ser conceituada como: preceito comum e obrigatório, emanado de poder competente e provido de sanção.54 Ou, ainda, uma regra de direito geral, abstrata e permanente, proclamada obrigatória pela vontade da autoridade competente, e expressa numa fórmula escrita.55

Por intermédio da definição da lei, podemos verificar três elementos que integram o conceito técnico do termo lei: Material, Formal e Instrumental.56

4.2.1 Elemento Material

O elemento material é o conteúdo da lei: "regra de direito geral, abstrata e permanente" – "preceito comum e obrigatório".

A matéria ou o conteúdo da lei é sempre uma "regra de direito", um "preceito comum". A lei tem o caráter de preceito, norma, regra de proceder, norma jurídica geral e, por consequência, abstrata e permanente. A lei é uma norma geral ou comum. Trata-se de um preceito comum, sendo dirigida a todos os membros da coletividade. É uma regra estabelecida não em vista de um caso individual, mas de todos os casos da mesma espécie. A lei obriga igualmente a todos os membros da sociedade sobre a qual estende a sua eficácia, isto é, a lei apresenta a característica da generalidade, surgindo dessa característica duas propriedades importantes: a lei é uma regra abstrata e permanente.

A lei disciplina uma situação abstrata. A lei é impessoal, ou seja, o legislador dispõe de situações jurídicas abstratamente, como homicídio, casamento, não considerando as pessoas individualmente abrangidas pela norma. A lei é abstrata, porque não visa a situações particulares ou concretas.

A lei é uma norma permanente, tendo continuidade no tempo, enquanto não for revogada por outra, ou ainda não se esgotar o tempo de sua vigência para as chamadas leis temporárias.

Outra propriedade da lei é a sua obrigatoriedade. A lei é obrigatória. A lei ordena, não exorta, não é uma teoria. A força obrigatória da lei é condição de sua eficácia.

4.2.2 Elemento Formal

O elemento formal refere-se à vontade do legislador. A lei deve emanar de poder competente. Se provier de órgão incompetente, perde a obrigatoriedade e, portanto, deixa de ser lei.

O órgão ou a autoridade competente para exercer o poder de legislar, nos Estados Democráticos, é o Parlamento eleito pelo povo, com alguma participação do Chefe de Governo. Nos regimes ditatoriais, o Poder Legislativo é absorvido pelo Ditador.

No Brasil, o art. 44 da Constituição Federal alude que: "O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal". O art. 48 do mesmo diploma legal, por sua vez, dita que: "Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União". Assim, podemos concluir que no atual sistema jurídico o processo legislativo é da competência do Congresso Nacional, com a participação do Presidente da República.

A vontade do legislador se exterioriza pelo processo legislativo, que analisaremos adiante.

4.2.3 Elemento Instrumental

O elemento instrumental é a fórmula escrita. A lei é sempre escrita, com o intuito de transmitir segurança social, além de ser uma forma mais didática de assimilar os preceitos. Conforme verificamos, muitos autores ligam o caráter escrito da lei à origem etimológica do vocábulo. O termo lei vem do latim legere, que significa ler, trata-se de um texto escrito, feito para ser lido. Por ser escrita, distingue-se a lei, norma escrita (jus scriptum – jus seriptum) do costume jurídico ou normas costumeiras, que são também normas jurídicas, mas não escritas (jus non scriptum – jus noiz seriptum).57

Ante todo o exposto, podemos estabelecer o seguinte esquema:

Elementos constitutivos da lei no sentido técnico	Material → Conteúdo da Lei Formal → A Vontade do Legislador Instrumental → Fórmula Escrita

Para que uma norma seja considerada "lei", sem seu sentido próprio e pleno, são necessários a presença dos três elementos: material, formal e instrumental. Quando faltar o elemento formal ou material, a norma será considerada uma lei imperfeita, sendo denominadas "leis meramente formais" ou "leis formais" e "leis meramente materiais" ou "leis materiais". Como exemplo de lei formal, podemos citar a lei que declara uma instituição filantrópica como de utilidade pública. Pelo contrário, como lei material podem ser considerados os regulamentos administrativos do Poder Executivo. Nesse sentido, verifica-se a lei no sentido lato do termo.